

0010992-05.2018.8.26.0482

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: ALESSANDRO CORREA LEITE

Comarca: Presidente Prudente

Foro: Foro de Presidente Prudente

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/04/2022

... Disse que não praticava tráfico de drogas. Afirmou que a fotografia de fl. 79 é sua. Quanto à fotografia de fl. 80, aduziu que desconhece a imagem. Alegou que na fotografia de fl. 79, estava segurando adubos para "espada de São Jorge".

Pois bem.

É cediço que no processo penal por tráfico/porte-posse de drogas e posse de armas/munições, normalmente, a prova acusatória ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Presidente Prudente

Foro de Presidente Prudente - 2ª Vara Criminal

Av. Cel. José Soares Marcondes, 2201, Presidente Prudente-SP - cep 19013-050

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

processo 0010992-05.2018.8.26.0482 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0010992-05.2018.8.26.0482

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Ofício - 117/2018

- DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Presidente Prudente,

286/2018 - DISE - Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Presidente

Prudente, 5252/2018 - Seccional - Presidente Prudente, 1244/2018 - Seccional -

Presidente Prudente

Autora:

Justiça Pública

Réu(s):

Marcos Aparecido Rodrigues Lira

Juiz de Direito: Dr. Alessandro Correa Leite

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofertou denúncia em face de MARCOS APARECIDO RODRIGUES LIRA, imputando-lhe a prática dos delitos previstos nos artigos 33, "caput", da Lei 11.343/06 e 12 da Lei 10.826/03, c.c. o artigo 69 do Código Penal.

Narra a denúncia que, no dia 24 de maio de 2018, por volta das 17h15, na Rua Felipe Vítor Trombim Souza, Jardim Alexandrina, nesta cidade e comarca de Presidente Prudente, o denunciado trazia consigo, visando o fornecimento a usuários, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 10,02 gramas de "Cannabis Sativa L.", vulgarmente conhecida por "maconha", divididos em três pedaços, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, classificada como droga alucinógena e despersonalizante.

Consta ainda que, no dia 24 de maio de 2018, no interior da residência situada na Rua Felipe Vítor Trombim Souza, nº 141, Jardim Alexandrina, nesta cidade e comarca

de Presidente Prudente, o denunciado possuía e mantinha sob sua guarda, 11 cartuchos integros da marca CBC, de calibre .22, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo a acusação, na data dos fatos, o denunciado trazia consigo, em via pública, a sobredita quantidade de "maconha", dividida em três pedaços, visando o fornecimento a usuários. Sucede que policiais militares em patrulhamento de rotina avistaram o denunciado na condução de uma bicicleta e empreendeu fuga, dispensando o entorpecente que trazia em mãos. Todavia, foi detido defronte sua residência. Na ocasião, foi apreendido em poder do denunciado um aparelho de telefone celular, cuja perícia revelou conversas importantes, apontando seu efetivo envolvimento com o tráfico de drogas, inclusive algumas mantidas na data da apreensão da droga. Consta, ainda, que, durante as investigações, constatou-se que o referido aparelho telefônico se encontrava registrado em nome do usuário Alexandre Rogério Machado dos Santos, que relatou ter entregue o aludido aparelho em troca de drogas, em data anterior à da prisão do denunciado. Prosseguindo às diligências, os policiais vistoriaram o imóvel do denunciado, ocasião em que localizaram um "pé de meia" no interior do guarda-roupas dele, cujo interior havia 11 munições intactas de calibre .22.

Autuado em flagrante, o denunciado livrou-se solto, após o pagamento de fiança (fl. 34).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia, reservando-se no direito de se manifestar após a instrução processual. Por fim, requereu a concessão de justiça gratuita (fls. 287/291).

Denúncia recebida aos 02/06/2021 (fl. 296). Pela mesma decisão, foi determinada a citação do acusado, bem como foi designada audiência de instrução, debates e julgamento.

O réu foi citado (fl. 324).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas, e, ao final, interrogado o acusado. Não houve requerimento de diligências e a instrução foi encerrada.

Em alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu, nos termos da denúncia.

A defesa, por seu turno, suscitou teses benéficas ao acusado. Em preliminar, arguiu nulidade em relação à busca pessoal realizada no acusado, por ausência de motivação idônea. No mérito, alegou insuficiência de provas para a condenação em relação a ambos os delitos, bem como que as drogas seriam destinadas a consumo pessoal do réu. Ainda, aduziu atipicidade material da conduta do acusado. Ao final, pugnou pela absolvição. Subsidiariamente, pleiteou a aplicação da pena no patamar mínimo, com fixação do regime inicial mais brando, e substituição da pena privativa por restritiva de direito (fls. 372/395).

É o relatório.

Fundamento e decido.

De proêmio, rejeito a preliminar de nulidade aventada pela defesa, pois, em verdade, não foi procedida nenhuma busca pessoal no acusado. Como será melhor destacado abaixo, os policiais, ao avistarem o réu, que demonstrou certo nervosismo, decidiram realizar uma abordagem de rotina, mas aquele empreendeu fuga, desvencilhando-se da droga que portava. Portanto, hígida a atuação dos policiais, sem razão o D. Defensor, não havendo que se falar em nulidade.

No mérito, a pretensão punitiva é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva está demonstrada: pelo auto de prisão em flagrante (fl. 07); pelo boletim de ocorrência (fls. 14/17); pelo auto de exibição/apreensão (fls. 18/19); pelos laudos periciais (fls. 55/56, 57/59); bem como pela prova oral colhida durante a instrução processual.

A autoria é certa e incide sobre o réu.

A testemunha Flávio Leandro Felizardo da Silva, policial militar, disse em juízo que estava em patrulhamento e avistou o réu. O réu ficou nervoso, tentou disfarçar. Resolveu abordar o réu, ao que ele começou a correr. O réu abandonou a bicicleta e continuou correndo. O outro policial conseguiu abordar o réu mais a frente. O réu jogou no chão a droga e continuou correndo, sendo abordado em frente à sua casa.

Presenciou o momento que o réu dispensou a droga, pois estava correndo atrás dele. Não se recorda do que o réu tenha falado. Perguntaram se tinha alguma coisa irregular na casa do réu, e este respondeu que tinha munição. A mãe do réu autorizou a revista, e realmente encontraram a munição. Não se recorda da justificativa do réu sobre a munição. Não conhecia o réu nos meios policiais. Não se recorda se foi apreendida balança de precisão ou algum apetrecho para o tráfico. O réu iniciou a fuga de bicicleta, e depois continuou fugindo a pé. Foi apreendido um celular na diligência.

A testemunha Emerson Luiz da Silva, policial militar aposentado, inicialmente disse em juízo que não se recordava da ocorrência. Posteriormente, relatou que se recordava vagamente, enfatizando que estavam patrulhando, e o indivíduo veio de bicicleta. Foram abordar esse indivíduo, que empreendeu fuga. Conseguiram pegar o indivíduo, que estava com as porções de maconha, em frente à sua residência. A mãe dele franqueou a entrada, e no quarto do réu, no guarda-roupas, foram encontradas as munições de calibre .22. Sobre o que o réu alegou, não se recorda.

Interrogado em juízo, o réu Marco Aparecido Rodrigues Lira disse que, realmente foi pego com maconha, mas possuía apenas um pedaço, que era para seu próprio uso. Relatou que haviam 11 munições e lhe pertenciam. Não sabe se foi apreendido um celular seu. Negou ter trocado drogas pelo celular que foi apreendido. Sustentou que desconhece as mensagens que estavam em seu celular, pertinentes aos entorpecentes. Disse que não praticava tráfico de drogas. Afirmou que a fotografia de fl. 79 é sua. Quanto à fotografia de fl. 80, aduziu que desconhece a imagem. Alegou que na fotografia de fl. 79, estava segurando adubos para "espada de são jorge".

Pois bem.

É cediço que no processo penal por tráfico/porte-posse de drogas e posse de armas/munições, normalmente, a prova acusatória consubstancia-se em depoimentos de policiais, civis ou militares, ou agentes penitenciários que efetivam a apreensão. E presume-se regular a atuação de agentes públicos investidos no cargo para segurança de todos, pois seria paradoxal que o Estado atribuísse a uma pessoa a execução do ato administrativo de polícia preventiva e repressiva, mas desmerecesse sua palavra.

É o raciocínio que mais se coaduna com a realidade das coisas, aplicado na jurisprudência em geral, tanto no Superior Tribunal de Justiça (REsp 151.150-SC, Rel. Min. José Dantas, j. 7.4.98) como no Supremo Tribunal Federal (HC 74.608-0-SP, Rel. Min Celso de Mello, j.18.2.97; HC 76.381-5-SP, Rel. Min Carlos Velloso, j. 16.6.98; HC 87.662-PE, Rel. Min Carlos Britto. J.5.9.06).

Nesse sentido, ainda:

VALIDADE DO DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, poder dever de ofício, da repressão penal. - O depoimento testemunhal do agente policial somente perderá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência (HC73.518-5 SP, Rel. Min. Celso de Mello, j.26.3.96). No caso dos autos, os policiais relataram, em essência, a apreensão da droga e das munições com o réu.

O réu, por sua vez, admitiu a propriedade da droga e das munições, ressaltando, no entanto, que o entorpecente se destinava a seu próprio consumo.

Confrontados os elementos de prova, afigura-se fidedigno o relato dos agentes públicos, que não teriam motivo para incriminar pessoas desconhecidas, conferindo-se, pois, valor probatório aos depoimentos dos policiais.

Contudo, cabe uma ressalva.

Conquanto a denúncia tenha relatado que o entorpecente localizado destinava-se à entrega, pelo réu, a terceiros, não foi isso que se verificou.

Deve ser salientado que não houve nenhuma "denúncia" extrajudicial a motivar a ação

policial, e não havia nenhuma pessoa juntamente com o réu, a evidenciar que ele estava a comercializar drogas no local.

A par disso, foram apreendidos apenas 10,02 g de maconha, ou seja, ínfima quantidade, que não se revela incompatível com o uso, mormente quando associada às demais circunstâncias do caso concreto.

Mais: não foi localizado com o réu, efetivamente, nenhum apetrecho à venda de drogas, como por exemplo saquinhos para embalagem do entorpecente e balança de precisão, tampouco dinheiro de qualquer monta.

O fato de terem sido localizados diálogos do réu com outros interlocutores, tratando da aquisição e possível repasse de entorpecentes, por si só, configurou apenas suspeita de que a maconha apreendida se destinava à mercancia, mesmo porque o tráfico propriamente dito não foi corroborado sob o crivo do contraditório, o que era imprescindível para a consumação e consequente condenação, à luz do que dispõe o art. 155 do CPP.

Nessa senda, valendo-se do disposto no art. 28, § 2º, da Lei 11.343/2006, levando em conta a pequena quantidade da droga, as circunstâncias em que foi apreendida, e a ausência de prova da mercancia, não se corrobora a tese de que esse entorpecente destinava-se ao tráfico.

Desse modo, aplicando-se no caso vertente o princípio in dubio pro reo, não há como condenar o acusado pelo crime de tráfico de drogas.

Impõe-se, assim, a desclassificação delitiva, cabendo salientar que o próprio réu admitiu que é usuário de drogas e a conclusão que se chega por meio deste processo, portanto, é que o entorpecente apreendido era destinado ao consumo pessoal do acusado, sendo de rigor sua condenação como incurso no delito descrito no art. 28 da Lei 11.343/2006.

No que tange à prática do crime previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/03, além da materialidade e autoria terem sido corroboradas pelas testemunhas policiais, o próprio réu confessou que realmente guardou as munições em sua residência e eram suas.

A par disso, a prova técnica atestou a potencialidade lesiva das munições.

Concluiu a i. Perita:

"Foram enviadas a este Núcleo de Perícias Criminalísticas, em embalagem plástica translúcida, sob o lacre D.8-DSPP 0004389, 11 (onze) cartuchos íntegros da marca 'CBC', com seus estojos confeccionados em metal dourado, de calibre real .22', dotados de projéteis ogivais em chumbo nu. Apresentaram massa média de 3.41 gramas e 25,01 mm de comprimento. Em conformidade com a norma NBR 5426, de janeiro de 1985, 3 (três) cartuchos foram testados, resultando na eficácia dos projéteis testados" (fl. 56 - destaquei).

É válido recordar que o delito em questão possui a seguinte redação:

"Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa: Pena - detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa".

Assim, para a configuração do tipo penal em apreço, basta a prática de tais condutas sem a comprovação de autorização e em desconformidade com determinação legal ou regulamentar.

Apesar do inconformismo defensivo, a figura penal em apreço é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo, para sua configuração, a ocorrência do efetivo prejuízo à sociedade.

Nesse sentido:

"Posse ilegal de acessório ou de munição Apreensão de munição ou de acessório de uso permitido no interior de residência Tipo penal de perigo abstrato Entendimento do art. 12 da Lei n. 10.826/2003 A apreensão de munição ou de acessório desacompanhados da respectiva arma não afasta a realização do tipo penal da posse ilegal de munição ou de acessório de uso permitido, uma vez que a potencialidade lesiva do objeto deve ser aferida de modo abstrato. Basta, assim, para o reconhecimento do crime o simples fato de o agente ter sido flagrado ocultando e mantendo aludida munição ou referido acessório sob sua guarda, sendo irrelevante a

circunstância de estarem eles acompanhados ou não da correspondente arma de fogo. (...) Com relação ao delito de posse ilegal de munição de uso permitido, não há que cogitar-se de atipicidade da conduta, em razão ausência de potencialidade lesiva. No laudo pericial de fls. 16/17, com efeito, constatou-se que: 'As peças acima descritas encontram-se aptas para uso em arma de fogo' (fls. 17). Ressalte-se, ainda, que, não havendo nenhum indício de que o acusado pretendia entregar a munição (como, por exemplo, se tivesse apresentado a exigida guia de trânsito expedida pela Polícia Federal, ou órgão por ela credenciado, consoante o art. 70, parágrafo 1º, do Decreto n. 5.123/04), nos termos do art. 32 da Lei n. 10.826/03, não há como presumir-se a sua boa-fé, sendo a conduta perpetrada típica. (...)" (TJSP, Apelação nº 0002235-86.2012.8.26.0270, Rel. Grassi Neto, j. 06/08/2015 - destaquei).

Registre-se que os tipos penais contidos na Lei nº 10.826/03, que revogou a Lei nº 9.437/97, objetivam a garantia e a preservação do estado de segurança, a integridade corporal, a vida, a saúde e o patrimônio de todos os cidadãos, indefinidamente considerados, contra possíveis atos que os exponham a perigo. Como dito, a simples realização de quaisquer das ações previstas no núcleo de um dos tipos penais contidos na lei basta para a consumação do crime. É irrelevante qualquer avaliação subsequente sobre a ocorrência, no caso concreto, de efetivo perigo à coletividade, salvo se caracterizar delito mais grave. Desse modo, o fato de as munições estarem desacompanhadas de arma não elide a responsabilidade penal do acusado.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO. MODIFICAÇÃO DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RESTRIÇÃO DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. EXAME EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. PORTE DE MUNIÇÃO. TIPICIDADE DA CONDUTA. 3. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO. 5. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, buscando a racionalidade do ordenamento jurídico e a funcionalidade do sistema recursal, vinha se firmando, mais recentemente, no sentido de ser imperiosa a restrição do cabimento do remédio constitucional às hipóteses previstas na Constituição Federal e no Código de Processo Penal. Atento a essa evolução hermenêutica, o Supremo Tribunal Federal passou a adotar decisões no sentido de não mais admitir habeas corpus que tenha por objetivo substituir o recurso ordinariamente cabível para a espécie. Precedentes. Contudo, devem ser analisadas as questões suscitadas na inicial no afã de verificar a existência de constrangimento ilegal evidente, a ser sanado mediante a concessão de habeas corpus de ofício, evitando-se prejuízos à ampla defesa e ao devido processo legal. 2. A orientação firmada nesta Corte Superior é no sentido de que o porte de munição, ainda que sem arma, é conduta típica. Portanto, o acórdão proferido pelo Tribunal a quo alinha-se ao entendimento sedimentado na Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça. 3. O Supremo Tribunal Federal, a partir do julgamento do HC n.º 97.256/RS, admitiu a possibilidade de substituição, como também de regime de cumprimento de pena mais brando que o fechado, observadas a proporcionalidade e a razoabilidade na aplicação do princípio da individualização da pena, medida que seria compatível com a benesse concedida. Todavia, no caso em apreço, consoante preceituam os arts. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, e 42 da Lei de Tóxicos, ainda que a pena tenha sido arbitrada no total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a fixação do regime prisional mais brando não se mostra adequada, haja vista a natureza e a quantidade de droga apreendida - 10,48g (dez gramas e 48 centigramas) de cocaína acondicionados em 23 porções e 17,40g (dezessete gramas e quarenta centigramas) de maconha - em poder do paciente. Precedentes do STJ. 4. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não tem cabimento, uma vez que não preenchido o requisito objetivo. 5. Ordem não conhecida". (STJ, HC 254.875/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, 5ª Turma, julgado em 18/12/2012, DJe 01/02/2013).

Da mesma maneira, respeitados entendimentos em contrário, incabível o

reconhecimento do chamado "princípio da insignificância".

Aliás, também nesse sentido também já decidiu o C. STJ:

"PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM O ENTENDIMENTO DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e ou munição, ante a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade de munição ou armas apreendidas. Súmula 568/STJ. 2. Agravo regimental a que se nega provimento". (AgRg no AREsp 1098040/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 24/08/2017 - destaquei).

"POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA PARA ATESTAR POTENCIALIDADE LESIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. 1. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância aos crimes de posse e de porte de arma de fogo e ou munição, ante a natureza de crimes de perigo abstrato, independentemente da quantidade de munição ou armas apreendidas. 2. Também é da jurisprudência iterativa deste Tribunal não ser necessária perícia para atestar potencialidade lesiva do artefato, justamente em razão da natureza do delito. 3. Por via de consequência, fica evidente que não há falar em inconstitucionalidade do crime, até porque é tema inapropriado ao veio do habeas corpus. 4. Ordem denegada". (HC 411.835/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 09/10/2017 - destaquei).

Ainda que assim não fosse, certo é que foram apreendidos nada menos que 11 cartuchos íntegros da aludida munição, cuja potencialidade lesiva foi atestada por perícia, bem como o réu já reúne contra si uma condenação com trânsito em julgado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003 (fls. 280/281), o que demonstra sua recalcitrância, deixando clara a alta periculosidade social da ação verificada nestes autos, tudo a reforçar ainda mais a impossibilidade de aplicação do princípio da bagatela, havendo distinguishing em relação aos julgados colacionados nos memoriais defensivos.

Portanto, a prova é bastante para a condenação criminal do réu, valendo ressaltar que, no caso concreto, não ficou evidenciada nenhuma circunstância excludente de ilicitude ou culpabilidade a beneficiá-lo.

Dito isto, passo a dosar a pena do réu.

Quanto ao delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, em que pese os maus antecedentes do acusado (fls. 280/282), é tecnicamente primário e, considerando o caso concreto, em que trazia consigo ínfima quantidade de maconha, entendo pertinente a aplicação da sanção mais branda, qual seja, advertência sobre os efeitos das drogas.

Quanto ao delito do art. 12 da Lei 10.826/2003, passo a individualizar a pena, de modo fundamentado e seguindo os parâmetros do artigo 68, "caput", do Código Penal. Na primeira fase da dosimetria penal, passo a analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal: culpabilidade (inerente ao tipo, sem considerações que possam aumentar significativamente a reprovabilidade da conduta); antecedentes (o réu ostenta maus antecedentes, tendo em vista a condenação definitiva no processo 0003607-40.2017.8.26.0482 - fl. 280); conduta social (nada a considerar); personalidade (nada a considerar); motivos do crime (próprios do tipo penal em questão); circunstâncias do crime (nada especial a considerar); consequências do crime (inerentes à espécie); comportamento da vítima (não influenciou para a prática delitiva).

Considerando que são oito circunstâncias judiciais, entendo que na primeira fase de fixação, a pena deve ser acrescida de 1/8 para cada circunstância judicial negativa, observando que a fração deve ser calculada sobre o intervalo da pena (pena máxima - pena mínima). Desse modo, observa-se um critério lógico, de que não havendo circunstâncias negativas, a pena-base fica no mínimo. Por outro lado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas, a pena-base vai crescendo,

proporcionalmente, até o máximo permitido pelo tipo penal.

Tal critério encontra respaldo tanto na jurisprudência do TJ/SP, como do STJ, como se vê no trecho abaixo, (extraído do acórdão proferido pela 2ª Câmara Criminal do TJ/SP, no julgamento da Apelação Criminal nº 0003469-93.2017.8.26.0346):

Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 8. No caso, considerando o intervalo entre a pena mínima e a máxima do crime de homicídio qualificado, que corresponde a 18 anos, revela-se proporcional a elevação de 2 anos e 3 meses por vetorial desabonadora e, portanto, não se infere qualquer excesso na fixação da básica em 18 anos de reclusão. 9. Writ não conhecido. (HC 590.354/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 24/08/2020). (g.n.)

Assim, diante dos maus antecedentes valorados, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo, em 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção.

Na segunda fase da dosimetria penal, não incidem agravantes. De outro lado, incidem as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa (réu nascido em 31/07/1997 – fls. 10, 14 e 27), razão pela qual atenuo a pena em 2/6, fixando a pena intermediária, contudo, em 01 (um) ano de detenção, tendo em vista que nesta fase a pena não pode ficar aquém do mínimo legal (súmula 231 do STJ).

Na terceira fase da dosimetria penal, não incidem causas de diminuição nem de aumento de pena, razão pela qual fixo a pena definitiva em 01 (um) ano de detenção. A pena de multa deve guardar proporção com a pena privativa de liberdade. Assim, fixo a pena de multa em 10 (dez) dias-multa. Baseado no critério da situação econômica do réu, arbitro cada dia-multa no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à data dos fatos, pois não há elementos sobre a capacidade financeira do réu que autorize a fixação do valor do dia-multa acima do mínimo legal.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, "c", do CP.

Feito um juízo de valoração da conduta do réu, verifico que a substituição da pena privativa de liberdade pela aplicação do disposto no artigo 44 do Código Penal, demonstra-se adequada e suficiente para a repressão do delito, não havendo, então, necessidade de mantê-lo no cárcere.

Assim, nos termos do artigo 44, §2º, do CP, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da condenação, na forma a ser especificada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais.

Ante o exposto, e considerando o mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado, e o faço para:

(a) ABSOLVER o réu MARCOS APARECIDO RODRIGUES LIRA, já qualificado nos autos, das imputações que lhe foram feitas nestes autos a respeito da prática do delito descrito no art. 33, "caput", da Lei 11.343/2006, o que faço com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal;

(b) CONDENAR o réu MARCOS APARECIDO RODRIGUES LIRA, já qualificado nos autos, por trazer consigo droga para fins de consumo próprio (art. 28 da Lei 11.343/2006), à sanção de advertência sobre os efeitos das drogas, nos termos do art. 28, I, da Lei 11.343/2006;

(c) CONDENAR o réu MARCOS APARECIDO RODRIGUES LIRA, qualificado nos autos, ao cumprimento de pena privativa de liberdade consistente em 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo vigente ao tempo dos fatos, a ser corrigido desde então, por infração ao artigo 12 da Lei 10.826/2003, SUBSTITUINDO a pena privativa por restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, pelo prazo da

condenação, na forma a ser especificada pelo MM. Juízo das Execuções Criminais. Em face da absolvição do acusado pelo delito de tráfico de drogas, e substituição da pena privativa quanto ao outro delito, restam ausentes os requisitos da segregação cautelar, razão pela qual deixo de decretar sua prisão preventiva. Deixo de fixar indenização mínima, tal qual consta no art. 387, IV, do CPP, pois sequer houve debate a respeito da dita indenização, de modo a respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, e diante da natureza difusa do sujeito passivo.

Considerando que o celular apreendido evidenciou mensagens de cunho delituoso por parte do réu (aquisição de drogas, ainda que para consumo), bem como que ele sequer comprovou a origem lícita do objeto, e relatou em juízo nem saber que o referido telefone fora apreendido, fica determinada a perda desse bem em prol da União, com fulcro no art. 91, II, alíneas "a" e "b", do Código Penal, devendo ser revertido diretamente ao Funad (art. 63, § 1º, da Lei 11.343/2006).

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP).

Nos termos do art. 336, "caput", do Código de Processo Penal, determino que o valor recolhido a título de fiança (R\$ 1.000,00 - fl. 66) seja destinado ao adimplemento das custas processuais.

Transitada em julgado, determino as seguintes providências:

- a) Atualize-se o histórico de partes;
- b) Comunique-se o IIRGD;
- c) Comunique-se o Juízo Eleitoral;
- d) Encaminhe-se à Senad a relação do bem apreendido, declarado perdido em favor da União, indicando o local em que se encontra e a entidade ou o órgão em cujo poder esteja (art. 63, § 4º, da Lei 11.343/2006);
- e) Expeça-se Guia DARE-SP, Código 230-6, relativamente ao depósito judicial de fl. 66, e a encaminhe por ofício ao Banco do Brasil para recolhimento;
- f) Expeça-se guia de execução definitiva.

P. Int.

Presidente Prudente-SP, 28 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA